

1500100-37.2022.8.26.0412

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SENIVALDO DOS REIS JUNIOR

Comarca: Palestina

Foro: Foro de Palestina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... topo do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente e estável, para praticar tais crimes. Embora a estabilidade e permanência do pacto, em nossa interpretação, não sejam requisitos legais em virtude da expressão “reiteradamente ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PALESTINA

Rua Capitão Faria, n. 1048, Fórum, Centro, Palestina, CEP 15470-000

Horário de atendimento ao público: das 12h30min às 19 horas

DATA: 18 de agosto de 2022

LOCAL: Sala de Audiências

AUTOS Nº: 1500100-37.2022.8.26.0412

JUIZ DE DIREITO: Dr. Senivaldo dos Reis Junior

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Dr. Gustavo Yamaguchi Miyazaki (presente)

RÉ: MARIA ANTONIA ROCHA RAMOS (presente)

ADVOGADO: Dr. Bárbara Maria Gimenés de Souza Lima (presente)

RÉU: HENRI ISAC DIAS ROSA (presente)

ADVOGADO: Dr. Antonio Teófilo Garcia Júnior (presente)

#### TERMO DE AUDIÊNCIA - PROCESSO DIGITAL

Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas comuns Malcom Montanare Mano e Marcelo de Freitas Tessari (nesta ordem). Nas inquirições, as perguntas iniciaram pelo MM. Juiz com a expressa concordância das partes.

As partes desistiram da inquirição da testemunha comum Júlio César de Toledo Garcia, o que foi homologado pelo MM. Juiz.

A seguir, a ré Maria Antonia Rocha Ramos e o réu Henri Isac Dias Rosa foram interrogados.

O registro da(s) oitiva(s) foi realizado mediante gravação digital (audiovisual), com a aquiescência das partes e testemunhas, conforme permissivo do artigo 405, § 1º, do CPP. Para maior fidelidade, os eventuais compromissos legais, as dispensas de compromisso e as contraditas foram registrados oralmente durante as oitivas. Considerando tratar-se de processo digital, a mídia digital (DVD) com a gravação audiovisual que segue o presente termo.

Estando encerrada a instrução, pelas partes foi dito que não tinham diligências complementares a requerer.

Prosseguindo-se aos debates orais, foi dada a palavra às partes, tendo a MM. Juiz facultado às partes a apresentação de alegações em mídia digital, por resumo das teses ou oralmente (com gravação audiovisual).

O representante do Ministério Público e as defesas apresentaram alegações finais em mídia digital (audiovisual).

Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de MARIA ANTÔNIA ROCHA RAMOS, vulgo “Maria do Tamboril” e HENRI ISAC DIAS ROSA, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 33 e do art. 35 da Lei 11.343/06, em concurso material, afirmando que no dia 23 de junho de 2022, por

volta das 08h00min, na Rua Adriano Trindade, n. 480, Jardim Tamboril nesta cidade e comarca de Palestina-SP, os acusados adquiriam, vendiam, ofereciam, tinham em depósito ou guardavam, para fins de comércio ilícito, 82 (oitenta e duas) porções de cocaína, pesando 46,99g (quarenta e seis gramas e novecentos e noventa miligramas), e 1 (uma) porção de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 6,83g (seis gramas e oitocentos e trinta miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de horário e local, MARIA ANTÔNIA ROCHA RAMOS, vulgo "Maria do Tamboril" e HENRI ISAC DIAS ROSA, ambos qualificados nos autos, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime acima descrito.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, policiais civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1500097-82.2022.8.26.0412 pelo Juízo de Direito da Comarca de Palestina, diligenciaram ao local dos fatos e foram recebidos por MARIA, moradora da edícula situada nos fundos, e por HENRI, morador do imóvel da frente. Na edícula, MARIA informou que guardava uma porção de "maconha" na cozinha. Os policiais Marcelo e Malcolm localizaram a porção de "maconha" indicada pela acusada e uma grande quantidade de saquinhos plásticos, já recortados, para embalar droga. No imóvel da frente, residência de HENRI, os policiais Júlio César e Malcolm localizaram 82 (oitenta e duas) porções de cocaína dentro de uma caixinha de papelão no guarda-roupas do acusado. HENRI declarou que guardou a droga em seu guarda-roupas a pedido de MARIA e que ela lhe prometeu a quantia de R\$ 200,00 (duzentos) reais pelo armazenamento. MARIA confirmou ser proprietária das porções de cocaína localizadas no guarda-roupas de HENRI e que adquiriu a droga em São José do Rio Preto para revender em Palestina.

Apurou-se, assim, que os denunciados se associaram previamente para a prática de tráfico de substâncias entorpecentes, ficando a acusada responsável pela aquisição e venda, e o acusado pela guarda da droga. A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O topo do art. 35 desta lei dispõe:

"Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei".

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Já o tipo objetivo do topo do art. 35 pune a associação para o tráfico (prescindindo, portanto, da concretização do tráfico), ao passo que o tipo subjetivo consiste no dolo específico de se associar, de forma permanente e estável, para praticar tais crimes. Embora a estabilidade e permanência do pacto, em nossa interpretação, não sejam requisitos legais em virtude da expressão "reiteradamente ou não", as decisões dos tribunais tem se consolidado neste sentido. O objeto material e jurídico é a paz pública.

Delito do art. 35 Lei de Drogas.

Analisando as provas contidas nos autos, não consigo vislumbrar os elementos caracterizados do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Não houve a demonstração inequívoca do vínculo associativo entre os acusados, indispensável para a comprovação do crime em questão, ou seja, não restaram preenchidos os requisitos da permanência, estabilidade, hierarquia, e divisão de

tarefas.

Assim, muito embora o conjunto probatório faça clara referência ao envolvimento dos réus no cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes, a verdade é que as circunstâncias do fato versado no presente feito indicam mais um mero concurso de agentes havido entre os denunciados do que uma verdadeira associação, que pressupõe, ainda que em grau mínimo, certa estabilidade, permanência, divisão de tarefas e vínculo hierárquico entre todos os agentes.

Ressalte-se que não ficou cabalmente demonstrado o animus associativo necessário para a caracterização da citada infração penal, uma vez que não basta a estabilidade e permanência, mas sim, cumulativamente com a repartição de tarefas e a hierarquia entre os agentes, pressupostos não elucidados no decorrer da persecutio criminis.

Delito do art. 33 da Lei de Drogas.

No caso em exame, há prova da existência dos crimes e de sua autoria.

A existência dos crimes está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/3); boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelos laudos periciais (fls. 19/22 e 221/223) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o delegado de polícia, Dr. Malcom Montanare Mano, assim respondeu: “voltou a responder pela Delegacia de Palestina e foi informado pelo investigador Marcelo apontado que a Maria do “Tamboril” estaria praticando tráfico em sua residência; as investigações indicaram que havia intensa movimentação na casa da ré, sendo que após diligências pediram mandado de busca e apreensão e cumpriram a diligência; chegando verificaram que o imóvel tinha duas partes, na parte da frente e um na parte de trás, sendo que na parte dos fundos era residência da acusada; quando chegou na residência dos fundos e a acusada os atendeu (estava dormindo) e foi informada do mandado e ela confessou que estaria traficando e teria drogas na residência; não foi encontrado valores relevantes; após foi até a parte da frente ajudar os demais policiais, sendo que conversou com o acusado Henri e que teria mudado recente da cidade de São Paulo, e que acabou confessando que tinha drogas na residência, sendo que receberia 200 reais para guardar a droga a pedido de Maria; apontou aonde estava o pacote e verificou que haviam várias porções de cocaína, devidamente embaladas; após retornou até o local aonde Maria estava e informou a acusada que Henri tinha dito acerca de ter guardado a droga e ela também confessou que teria entregue para ele a troca de 200 reais; no lixo da casa foram encontrados diversos saquinhos transparentes recortados que eram usados para embalagem das drogas encontradas junto com o outro acusado; a acusada argumentou que fazia traficância para se sustentar; a acusada disse que teria ido em Rio Preto comprar cocaína e ela mesmo teria embalado toda a droga, sendo que tinha deixado na casa do Henri visto que teria ficado cismada com alguma coisa, na noite anterior a diligência do mandado; no mesmo lote haviam duas residências, duas construções, o muro era bem baixo para poder adentrar, mas não havia portões para entrada; não havia acesso por portas de uma casa à outra; a residência da frente era do pai do Henri e de trás alugada pela acusada Maria; a denúncia que foi colhida pelo investigador Marcelo colheu é que Maria estava traficando no local, nada dizendo, em início acerca de ter casal, mas sim de Maria estaria praticando tráfico, conhecida como Maria do Tamboril; o acusado Henri apareceu posteriormente após o cumprimento do mandado, visto estar no local do cumprimento do mandado de busca e apreensão; a acusada não ofereceu qualquer tipo de resistência no cumprimento da diligência; apenas, em primeiro momento, nada falou sobre a droga na casa do Henri; foram apreendidas 82 porções de cocaína; esta droga teria sido adquirida em São José do Rio Preto; foi titular por 3 anos e meio e está há cerca de 6 meses como respondente da Delegacia; cada porção era vendida ao importe de 50 reais.”

A testemunha Marcelo Tessari, em juízo disse o seguinte: “participou das investigações acerca do presente procedimento que resultou na apreensão de drogas no local dos fatos; recebeu informações na Delegacia que a sra. Maria estaria praticando a traficância em sua residência; assim sendo iniciou as investigações e requereu mandado de busca e apreensão para averiguar o local; nas diligências foram

encontradas porções de cocaína, sendo que tais drogas foram encontradas no local aonde o acusado estava; ao cumprir o mandado e por ser no mesmo terreno, acabou-se por fazer a diligência no mesmo local, sendo que fizeram as buscas na casa da frente e de trás, de modo que o acusado Henri disse que estaria recebendo para guardar a droga para Maria; foram encontradas drogas na casa da Maria e também no casa do Henri, sendo que a maioria da droga foi encontrada na casa da ré; não conhecia o acusado Henri; as notícias sobre o tráfico de drogas começaram a eclodir em novembro de 2021; sendo que anteriormente fizeram diligências no local de residência da acusada, inclusive com expedição de mandado anterior; as notícias do tráfico da acusada Maria já fazia bastante tempo; quanto ao acusado o encontro foi derivado do mandado de busca no local; não se sabe de informações de outros delitos envolvendo a acusada; a casa era muito bem cuidada, em razão de ter experiência de outras diligências, por razão, inclusive, da acusada ter uma filha menor de idade." MARIA ANTONIA ROCHA RAMOS, interrogada em juízo, disse que "entregou os saquinhos com cocaína para o acusado Henri, sendo que ele não sabia o que estaria guardando; adquiriu a droga em São José do Rio Preto, sendo que não sabe quem era a pessoa; cada saquinho era vendido a cerca de 50 reais; pelo produto pagou cerca de 500 reais; não se recorda quanto tempo o Henri veio morar na parte da frente da residência; é usuária de maconha; não sabe dizer os motivos por que escolheu a droga cocaína para vender na cidade; já fazia algum tempo que traficava, mas não era regularmente, sendo que fazia em momentos de desespero de condições econômicas; a droga maconha encontrada no dia dos fatos era para o seu uso; está arrependida pela prática do delito;

HENRI ISAC DIAS ROSA, em seu interrogatório disse que "na segunda-feira estava em Rio Preto, sendo que na quarta-feira Maria a chamou para guardar a droga, mas não sabia a quantidade; sendo que na quinta-feira quando estava dormindo acordou com os policiais dentro da sua casa abrindo a porta do seu quarto, realizando diligência de mandado de busca e apreensão; de pronto já apresentou aonde estava a droga; foi até a casa dela e ela lhe entregou uma caixa de papelão com fita crepe; aduziu que sabia que estaria guardando droga, mas não sabia qual era e quanto tinha; iria receber a quantia de 200 reais na próxima segunda-feira; chegou em Palestina no final de dezembro de 2021; ficou sabendo que Maria era traficante em meados de janeiro após perceber intensa movimentação para a casa de Maria; viu a corré embalando maconha, sabia que era para uso próprio; sempre que saía da frente do computador percebia que ali era ponto de tráfico pela quantidade pessoas que entravam e saíam da casa; recorda-se de ter visto intensa movimentação na casa da corré por pelo menos 3 vezes, visto que pouco saía; morava antes em São Paulo; chegou a tentar emprego na cidade em loja de calçados."

Independentemente de os acusados terem confessados os fatos, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando existência das condutas de ter em depósito, guardar, adquirir, fornecer e vender.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar os réus.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes os réus e seus defensores, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o estado darão aos policiais créditos para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos)

a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juizes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juizes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

HENRI ISAC DIAS ROSA- art. 33 Lei nº 11.343/06

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Portanto, em referência ao critério da natureza da droga, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merecem valoração nesta fase a maconha e cocaína, sendo que esta em especial (e em maior grau o crack, seu derivado), por causar severa dependência em seus usuários. O STJ, responsável pela uniformização da aplicação do direito infraconstitucional, tem entendido como razoável o aumento de um décimo na pena-base para quantias em torno de 100g de cocaína.

"No caso, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento o art. 42 da Lei de Drogas, elevou a pena-base em 1 ano, em razão da aferição desfavorável da quantidade e da natureza da droga (120 g de cocaína).

Tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, uma vez que significativo o quantum e altamente nociva a substâncias apreendida, não se identifica a alegada contrariedade do art. 59 do CP, sobretudo quando tais circunstâncias foram elencadas legalmente como preponderantes, e as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão." STJ, HC 431541/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Assim, conjugando as drogas apreendidas com as quantidades encontradas, aplico um aumento de 1/6 da pena-base ao acusado.

Fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa (inciso II do art. 65 do Código Penal), conforme documento de fl. 55, bem como a atenuante da confissão (artigo 65, inciso II, alínea "d" do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena indicada em 1/6 (um sexto), observado o disposto na Súmula 231 do STJ, pelo que a pena deve ser retornada ao mínimo legal.

Terceira etapa. É causa de aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Considerando a primariedade técnica do réu, mister a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A redução, ao caso em tela, não deve ser a máxima, visto a quantidade de drogas, bem como a recompensa financeira que receberia em razão de guardar as substâncias entorpecentes.

Entendo, portanto, em razão da quantidade, é caso de diminuição da pena na fração de 1/2. Pelo que fica a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

O regime inicial aplicado é o aberto.

Quanto à substituição. Entendo que é inaplicável ao caso em tela. E acompanho voto do Desembargador Ricardo Sale Júnior da 15ª Câmara Criminal:

"Não se desconhece o teor da Resolução nº 5 do Senado Federal: "É suspensa a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS". Todavia, evidenciadas as peculiaridades do caso concreto, não se impõe a referida substituição, uma vez que a culpabilidade do apelado não autoriza essa benesse (cf. artigo 44, inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena privativa de liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na medida em que repreende agente que cometeu grave crime de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não se afigurando socialmente recomendável, portanto, a referida substituição." (TJSP; Apelação Criminal 1505930-85.2021.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022) MARIA ANTONIA ROCHA RAMOS

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Portanto, em referência ao critério da natureza da droga, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merecem valoração nesta fase a maconha e cocaína, sendo que esta em especial (e em maior grau o crack, seu derivado), por causar severa dependência em seus usuários. O STJ, responsável pela uniformização da aplicação do direito infraconstitucional, tem entendido como razoável o aumento de um décimo na pena-base para quantias em torno de 100g de cocaína.

"No caso, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento o art. 42 da Lei de Drogas, elevou a pena-base em 1 ano, em razão da aferição desfavorável da quantidade e da natureza da droga (120 g de cocaína).

Tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, uma vez que significativo o quantum e altamente nociva a substâncias apreendida, não se identifica a alegada contrariedade do art. 59 do CP, sobretudo quando tais circunstâncias foram elencadas legalmente como preponderantes, e as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão." STJ, HC 431541/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Também, é de se considerar a circunstância desfavorável em razão de se verificar que a acusada praticava o comércio há vários meses, conforme diligências realizadas pela Polícia Civil, e afirmado pelo corréu.

Assim, conjugando as drogas apreendidas com as quantidades encontradas, aplico um aumento de 1/4 da pena-base à acusada.

Fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão (artigo 65, inciso II, alínea "d" do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena indicada em 1/6 (um sexto), pelo que a pena fica em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 520 dias-multa.

Terceira etapa. Ademais, incabível o redutor.

Com efeito, a Lei nº 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante que debuta na seara, com a previsão de causa especial de diminuição da pena.

E, ainda assim, respeitosamente, não há se falar em aplicação automática do redutor, relevante, para tal mister, uma bem feita interpretação teleológica dos requisitos legais enumerados no art. 33, §4º da lei de regência, aliás, em consonância com a mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores. Observo que "o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa" (STJ, HC n. 406.667/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/10/2017). A omissão em relação a qualquer deles implica indeferimento.

Por vezes, isso é fato, réus 'convivem' com a sociedade na condição de primários que, convenhamos, é um elemento aleatório e demanda eventual sorte do suspeito, exatamente por não ter, anteriormente, sido flagrado pela Polícia em ações deste jaez.

De todo o modo, 'per se', não basta a circunstância de não ter sido condenado para merecer esse benefício. Outrossim, ainda na condição técnica de primário, o faltoso pode ver recusada a redução do parágrafo 4º por conta da quantidade de estupefacientes.

Lição de igual teor nos é prestada pela Min. CARMEN LÚCIA: "(...) A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas" (STF, RHC 94.806/PR, 1.<sup>a</sup> Turma, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 16/04/2010).

A prova circunstancial pode escrachar a vinculação do réu em relação aos fornecedores profissionais, ou seja, a organizações de criminosos voltadas para a traficância.

Data vênia, como predica o Processo Civil, "fatos notórios independem de provas" 'id quod plerumque accidit', arts. 3º do CPP c.c. 375, do NCPC) e, isso nos parece óbvio, nenhum neófito irá receber quantidades de entorpecentes que, no correspondente mercado, implicam dinheiro vivo, sem contarem com a fidúcia dos distribuidores. Esse elemento implica na conclusão de que já se entrosaram com bandidos atuantes naquela seara, de sorte a não merecerem o redutor.

Não ao acaso a Min. ROSA WEBER, novamente no Pretório Excelso, legou escólio pelo qual "a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (HC 122.594/SP, j. 23.9.2014).

Não se há confundir a teleologia do redutor, voltado para infratores de menor potencial, o que não é o caso. Oportuno remeter ao escólio do E. Des. GERALDO WOHLERS, da 3ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça em eminente voto na Apel. n. 0001734-82.2010.8.26.0568:

"(...) A diminuição hoje admitida pelo artigo 33, § 4o, da Lei nº 11.343/06 não está inquinada de inconstitucionalidade. Trata-se de mecanismo que fornece ao Magistrado maior amplitude e liberdade de atuação para aferir no caso concreto a retribuição penal a ser suportada pelo transgressor, prestigiando o princípio constitucional da individualização da pena, direito fundamental insculpido no artigo 5º, XLIV, da CF.

Todavia, referida redução não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A 'mens legis' da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que

não denotam perseverança criminosas, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas".

Portanto, rememorando que foram encontradas com a ré a substância de cocaína, bem como afirmação, inclusive do corréu, que verificou que Maria era traficante pela intensa movimentação que presenciava na casa aos fundos, é de se não conceder essa hipótese legislativa.

Regime inicial de cumprimento. Considerando o total de pena imposto e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial deverá ser, conforme orientação jurisprudencial, o fechado.

"O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal." STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

ABSOLVER, com base no art. 386, inciso VII do CPP, os réus MARIA ANTÔNIA ROCHA RAMOS, vulgo "Maria do Tamboril" e HENRI ISAC DIAS ROSA quanto à imputação do delito previsto no topo do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

CONDENAR HENRI ISAC DIAS ROSA, primário, à pena de reclusão, pelo prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial aberto, bem como a 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

CONDENAR MARIA ANTÔNIA ROCHA RAMOS, vulgo "Maria do Tamboril", primário, à pena de reclusão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado, bem como a 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06

Ao acusado Henri Isac Dias Rosa, expeça-se alvará de soltura, caso não esteja preso por outro delito.

Quanto à ré Maria Antônia Rocha Ramos, confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta da acusada, as razões das prisões cautelares estão mantidas.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

"3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado.

4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas). 5. Ordem denegada." STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança nos regimes prisionais.

Comunique-se ao eminente Relator do HC nº 763318 / SP (2022/0251465-2), Ministro Joel Ilan Paciornik a respeito da prolação desta decisão.

Condene os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a



assistência judiciária gratuita, uma vez que foram nomeados advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Sentença Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Consultadas as partes quanto ao interesse em recorrer, conforme manifestações lançadas ao final da sentença, o Ministério Público e a defesa do corréu Henri Isac Dias Rosa informaram não terem interesse em recorrer, porém a defesa da corré Maria Antonia Rocha Ramos, manifestou-se pelo interesse em recorrer.

Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pela corré Maria Antonia Rocha Ramos e pela sua defesa técnica. Dê-se vista à defesa para apresentação das suas razões de apelação. Depois, dê-se vista ao Ministério Público para contrariedade. Depois de apresentadas as razões e as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do apelo, com as homenagens deste juízo. Ficam as partes intimadas".

Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Termo digitado e lavrado por mim, \_\_\_\_ (Antonio Silvio Volpe Sagliocco, Matrícula 94.430-4), Organizador das Audiências. Termo digitalmente assinado pelo magistrado.